Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 7ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810373

Processo nº 0057706-69.2021.8.17.2001

AUTOR: ALEXANDRE HENRIQUE PESSOA NEGROMONTE
REPRESENTANTE: ALVARO AUGUSTO MENDES NEGROMONTE

REU: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO

SENTENÇA

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COVID19. UTI. PRESCRIÇÃO DO FÁRMACO ACTEMRA (TOCILIZUMABE). RECUSA DA OPERADORA. MEDICAMENTO APROVADO PELA ANVISA. TRATAMENTO OFF-LABEL. IMPRESCINDIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO DIANTE DO INSUCESSO DE OUTROS TRATAMENTOS. NEGATIVA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA EVIDENCIADO. ABUSIVIDADE. LEI 9.656/98. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROCEDÊNCIA.

- Preliminar de ilegitimidade passiva do nosocômio corréu. Hospital Português que prestou o atendimento necessário ao tratamento do paciente, não podendo responder pela negativa da operadora de plano de saúde, inexistindo, portanto, qualquer pretensão a ser formulada em seu desfavor. Acolhida.

- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Súmula 608, STJ.

- Em que pese o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento não vinculante dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704, a amplitude da cobertura nos contratos de plano de saúde não pode se submeter aos trâmites burocráticos delongados delongada da agência setorial, sendo de rigor privilegiar, mercê da notória evolução científica da medicina e da primazia da vida e da saúde, os princípios da dignidade da pessoa humana, da defesa do consumidor, da informação e da boa-fé objetiva.

- O plano de saúde pode estabelecer quais as doenças que serão cobertas, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser alcançado pelo paciente, especificamente requisitados pelo médico assistente.

- Imprescindibilidade do medicamento (ACACTEMRA (TOCILIZUMABE) diante do insucesso de outros tratamentos, conforme requisitado pelo médico assistente.

- Em efeito, havendo prescrição médica para um tratamento específico, visando restabelecer a saúde do paciente, sendo a doença coberta pelo plano, não pode a seguradora limitar o tratamento.

- A negativa do custeio, fundamentada em cláusula contratual ou em interpretação equivocada de realidade dos fatos rende ensejo à indenização por dano moral, o qual se configura *in re ipsa.* Aplicação da Súmula 35 do TJPE.

- Pedidos que se julgam procedentes.

Vistos, etc.

ALEXANDRE HENRIQUE PESSOA NEGROMONTE, qualificada nos autos, promove esta **AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS** em face de **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO**, igualmente qualificados, aduzindo em breve suma que, ostentando a condição de segurada da promovida e estando em dia com as prestações decorrentes do vigorante contrato de assistência médico-hospitalar, fora internado, em 21.05.2021, em virtude da doença COVID19, sendo entubado do dia 25.05.2021 ao dia 03.06.2021.

Afirma que, durante seu tratamento em UTI, foi administrado o medicamento ACTEMRA 20MG/ML, 10 doses e o EQUIPO INTRAFIX SAFESET, devidamente recomendados por seu médico assistente.

Prosseguindo, aduz que, no dia 12 de julho de 2021, recebeu em sua casa a cobrança do medicamento ACTEMRA 20MG/ML, pelo réu Hospital Português, no valor de R$ 8.866,76 (oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), sob a alegação que a SulAmerica havia se negado a custear o medicamento pelo motivo de não constar no rol obrigatório da ANS, além de não ser recomendado pela ANVISA.

Em vista deste estado de coisas, invocando a legislação pertinente, veio o segurado a Juízo pleitear a condenação da operadora promovida no custeio integral do medicamento ACTEMRA 20MG/ML (R$ no valor de R$ 8.866,76 (oito mil oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), além de indenização por danos morais estimado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Despacho inaugural proferido no Id, 86035571 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3728613&ca=0f61623f53b88e64a52375dadb722ae343cbeac00c57f8b4f8d15a26a3085f5cdc764b determinando a citação da Ré e deferindo a gratuidade da justiça.

Regularmente citada, o Réu Hospital Português ofertou contestação (ID nº 88200634 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3728613&ca=0f61623f53b88e64a52375dadb722ae343cbeac00c57f8b4f8d15a26a3085f5cdc764b alegando em sede de preliminar sua ilegitimidade passiva *ad causam* , sob o argumento de que não há *"obrigação ou conduta imputada ao Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, não há justificativa para a sua permanência no polo passivoda lide".* No mérito, afirmou que a cobrança do medicamento ministrado no autor, ACTEMRA 20MG/ML, foi uma medida que se impunha para resguardar seu crédito, posto que sua cobertura pelo plano de saúde havia sido negada. Pugnou ao final para sua exclusão da lide ou alternativamente, a improcedência da ação.

A Ré Súl América apresentou sua peça de bloqueio no Id. 90395977 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3728613&ca=0f61623f53b88e64a52375dadb722ae343cbeac00c57f8b4f8d15a26a3085f5cdc764b pelejando pela estrita observância do aforismo *pacta sunt servanda,* posto tratar-se de medicamento

experimental (off label) que não consta expressamente do Rol de Procedimentos da ANS e expressamente excluído no contrato. Diz não existir caracterização de quaisquer danos indenizáveis, clamando pela improcedência de demanda.

Houve Réplica no Id. 92081746 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3728613&ca=0f61623f53b88e64a52375dadb722ae343cbeac00c57f8b4f8d15a26a3085f5cdc764b

Os contendores não manifestaram interesse na dilação probatória ou na autocomposição, conforme petições de ID nº 94226243 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3728613&ca=0f61623f53b88e64a52375dadb722ae343cbeac00c57f8b4f8d15a26a3085f5cdc764b 93550180 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3728613&ca=0f61623f53b88e64a52375dadb722ae343cbeac00c57f8b4f8d15a26a3085f5cdc764b e 92924473 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3728613&ca=0f61623f53b88e64a52375dadb722ae343cbeac00c57f8b4f8d15a26a3085f5cdc764b

Razões finais apresentadas no Id. 96372711 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3728613&ca=0f61623f53b88e64a52375dadb722ae343cbeac00c57f8b4f8d15a26a3085f5cdc764b 96713478 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3728613&ca=0f61623f53b88e64a52375dadb722ae343cbeac00c57f8b4f8d15a26a3085f5cdc764b

É o relatório. Decido.

Vieram-me então os autos conclusos.

Em atenção à ilegitimidade passiva suscitada pela Réu Hospital Real Português, tenho por imperativo acolhê-la. Explico.

A utilização da medicação ACTEMRA 20MG/ML, 10 doses e o EQUIPO INTRAFIX SAFESET, foi medida que se impôs para salvar a vida do autor, diante da negativa de custeio do plano de saúde SULAMERICA (Id. 85667272 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3728613&ca=0f61623f53b88e64a52375dadb722ae343cbeac00c57f8b4f8d15a26a3085f5cdc764b enquanto o autor se encontrava internado na UTI devido a complicações ocasionadas pela COVID19.

Assim, o réu Hospital Português prestou o atendimento necessário ao tratamento do paciente, cobrando ao final, a quantia devida, posto que a negativa de cobertura se deu pela operadora do plano de saúde, inexistindo, qualquer obrigação ou conduta a se aplicar em seu desfavor.

Face a esse estado de coisas, acolho a prefacial de impertinência subjetiva do Real Hospital de BeneciÊncia Portuguesa, para todos os jurídicos e legais efeitos.

Estando o feito em ordem e inexistindo questões prévias, adentro de logo ao *meritum causae.*

Versam os autos a respeito de negativa do plano de saúde no custei do medicamento ACTEMRA 20MG/ML, 10 doses e o EQUIPO INTRAFIX SAFESET, sob a justificativa de não constar no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e ser considerado um tratamento "offlabel" (experimental) .

Neste sentido, a hipótese vertente atrai a proteção da legislação consumerista, em face da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, a teor da **Súmula 608 do STJ**.

Acerca da taxatividade ou exemplificatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, alguns aspectos de denodado relevo merecem aprofundamento.

A) Prolegômenos

Dentro deste panorama, denota-se que a operadora demandada sustenta sua recusa à cobertura sob argumento de que, sendo contrato submetido à Lei nº 9.656/98, o tratamento solicitado não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, além de ser consideral off label, olvidando assim as garantias constitucionais e da legislação de que gozam os consumidores.

Há de se destacar que, em conformidade com o regramento estampado na legislação consumerista, o direito lastreado na boa fé ostenta especial relevância em prol do consumidor, mormente quando se cuida de situação de risco no que concerne à higidez física dos pacientes (art. 5º da Constituição Federal) situação essa que se acha patenteada no teor do documento médico que sinaliza para a necessidade de submeter o suplicante, vítima de complicação provocada pela COVID19 (entubado em UTI), ao tratamento com a medicação ACTEMRA 20MG/ML, 10 doses e o EQUIPO INTRAFIX SAFESET.

Na prática, o rol da ANS tem sido considerado taxativo pelo órgão regulador e os planos têm se negado, frequentemente, a oferecer tratamentos e tecnologias que não constem dele, o que não raro leva pacientes à judicialização. Por outro lado, o entendimento histórico dos tribunais do país, que são predominantemente favoráveis a uma interpretação mais ampla, considera a lista de procedimentos como referência exemplificativa. A maioria deles possui jurisprudência consolidada em favor de um rol exemplificativo.

Para além disso, cumpre assentar que o CDC é norma de ordem pública (art. 5º, XXXII, da CF), sendo certo que o plano de assistência médico-hospitalar é contrato de trato sucessivo, que se renova a cada mensalidade.

A Constituição Federal assim prescreve:

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ocorre que, bem recentemente, após séria divergência visceral entre as 3ª e 4ª Turmas, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Segunda Seção, formou maioria no bojo dos REsp 1886929 e EREsp 1889704 para o fim de firmar diretriz nos seguintes termos:

> 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;
>
> 2. Se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;
>
> 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;
>
> 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva *ad causam* da ANS.

A justificativa principal para impor essa ideação é que a taxatividade do rol da ANS seria fundamental para o funcionamento adequado do sistema de saúde suplementar, garantindo proteção, inclusive, para os beneficiários – os quais poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem de arcar indiscriminadamente com ordens judiciais para a cobertura de procedimentos fora da lista da autarquia.

Com as devidas vênias ao entendimento colegiado da Corte de Uniformização Infraconstitucional, a solução encontrada não se me parece a melhor e mais apropriada para solução desse tipo de demanda envolvendo vida e saúde.

B) Da evolução científico-tecnológica da medicina x burocracia da ANS

De efeito, não se pode negar que a benfazeja evolução científica das ciências médicas, notadamente oncológica e robótica, sobe o edifício fático-jurídico de elevador, enquanto a burocracia administrativa da agência setorial continua caminhando lentamente e de escada.

Ademais, a crença de que a limitação da cobertura importaria segurança e benefício econômico para os consumidores ignora o fato de que, no nosso sistema capitalista acumulador, a incorporação do lucro alcança inclusive os incentivos concedidos pelas instituições públicas, inexistindo a mais mínima comprovação de que as operadoras repassarão o deságio atuarial para as prestações custeadas pelos usuários.

Entender que o rol é taxativo significa o melhor dos mundos apenas para as operadoras: será delas, e tão somente delas, o lucro e os benefícios advindos da isenção de prestar serviço de saúde fora do multicitado rol, enquanto os consumidores continuarão arcando para com as mensalidades e terão cobertura limitada até que as conveniências e oportunidades dos órgãos setoriais entendam por bem incorporar os novos tratamentos à lista de cobertura mínima obrigatória.

Para além disso, eximir a operadora de plano ou seguro de saúde da obrigação de arcar com tratamento não constante do rol da ANS, só porque existe outro equivalente já incorporado ao rol, seria o mesmo de extirpar do médico assistente, que acompanha de perto a jornada do paciente, a autoridade de definir, no caso concreto, qual seja a melhor terapêutica para garantir a saúde física e mental daquele.

Em boa verdade, **o só-cogitar que a ANS atualizará celeremente o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para se manter *pari passu* com a evolução da medicina, valendo-se da participação social e dos demais atores do setor, soa de uma credulidade quase pueril**.

Vale citar como exemplos emblemáticos as diversas técnicas de robótica, **exames laboratoriais e medicamentos**, já utilizadas há alguns anos, mas que simplesmente ainda não integram a lista da agência setorial e por isso são reiteradamente denegadas pelas maiores (se não únicas) beneficiárias desse retardo/desinteresse: as próprias operadoras.

Daí exsurge a atuação do Judiciário para equilibrar tais relações e corrigir as dicotomias manifestas.

Neste rumo de pensamento, também recentemente, diversas instituições médicas (dentre as quais Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT) e a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN), fizeram publicar Carta Pública combatendo essa *ratio* excludente, nos seguintes termos:

"Nos manifestamos pela ampliação da discussão a respeito desta interpretação jurídica e firmamos posição em defesa de caráter não restritivo, podendo este servir como um balizador de condutas e nunca como um limite pétreo do cuidado. Reconhecemos a necessidade da sustentabilidade do sistema de saúde suplementar e, por isso, sugerimos que o STJ module sua decisão, legitimando a realidade atual: rol deve ser prestigiado sempre que possível e sua atualização deve ser mais célere e com a discussão técnica com as Sociedades de Especialidades. No entanto, se a via judicial for a saída encontrada pelo paciente para assegurar seu acesso ao tratamento recomendado pelo seu médico, que o juiz possa analisar caso a caso, podendo entender que em determinadas situações, a ANS não deu a resposta mais adequada para a sociedade".

Calha o registro de que inexiste a mais mínima evidência de que, desde sua adesão, a parte autora tenha sido expressamente comunicada de que seu futuro atendimento seria condicionado ao que, dentre as opções agora finitas da autarquia federal, melhor aprouvesse à operadora ré.

C) Da violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana; direito à informação e da boa-fé objetiva

O **direito à informação** é direito à prestação positiva oponível a todo aquele que fornece produtos e serviços no mercado de consumo (art. 5º, XIV, CF e art. 6º, III, CDC). Assim, não se dirige apenas negativamente ao poder político, mas positivamente ao agente de atividade econômica. Esse sentido, próprio do direito do consumidor, cobra explicações de seu enquadramento como espécie do gênero direitos fundamentais.

O **dever de informar**, de seu turno, tem raiz no tradicional princípio da boa-fé objetiva, significante da representação que um comportamento provoca no outro, de conduta matrizada na lealdade, na correção, na probidade, na confiança, na ausência de intenção lesiva ou prejudicial. A **boa-fé objetiva** é regra de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam.

É bem por isso que o princípio da boa-fé objetiva vem sendo refuncionalizado, otimizando-se sua dimensão de cláusula geral, de modo a servir de parâmetro de validade dos contratos, principalmente nas condições gerais dos contratos de consumo, definidora dos limites de autorrealização do fornecedor e do efetivo cumprimento do dever de informar.

A Constituição brasileira (art. 170) estabelece que a atividade econômica deve observar, dentre outros, o **princípio de defesa do consumidor**. O princípio é dirigido não só ao Estado, mas, precípua e principalmente, aos agentes econômicos, como é o caso da operadora demandada. O princípio é abrangente do direito à informação, referido explicitamente no artigo 5º, XIV.

Acima de todo esse pensar, como se não fosse suficiente, está o fundamento republicano da **dignidade da pessoa humana** (art. 1º, III), máxima essa que já tornaria inviável a tese de taxatividade do rol da ANS.

O foco nos mencionados princípios, portanto, milita em favor da parte vulnerável, o consumidor/contratante.

D) Da não vinculatividade do resultado do julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704

Por fim, saliento que o julgamento dos mencionados recursos (STJ) não foi objeto de afetação, tampouco observou o rito dos recursos repetitivos, exsurgindo portanto mais como uma diretriz do que uma sedimentação jurisprudencial vinculante.

Bem por essas razões, continuo a concluir ser o rol de procedimentos elaborados e estabelecidos pela ANS de **caráter meramente exemplificativo**, ou seja, a lista indica o mínimo de procedimentos que devem ser cobertos, não sendo dado à operadora o poder para restringir ou limitar arbitrariamente sua responsabilidade, que advém da lei e dos contratos celebrados com os consumidores, sendo irrelevante ao caso dos autos a falta de expressa anotação do procedimento em resolução da ANS.

Consoante a Lei Consumerista, as cláusulas restritivas de direitos devem estar redigidas de maneira destacada, possibilitando assim a fácil percepção da parte contratante que, por se tratar de simples aderente e ostentar posição econômica induvidosamente inferior, qualifica-se como hipossuficiente.

Nesta esteira, inolvide-se a previsão legal contida no §4º do artigo 54 do referido diploma legal que, ao tratar dos contratos de adesão, dispõe, *in verbis*: *"as cláusulas que implicarem limitações de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão".*

Conforme deflui da singela leitura da defesa, a única ressalva da ré repousa no fato de que não estaria obrigada a custear a técnica e o material especificamente solicitado pelo médico assistente.

Todavia, ainda que haja cláusula contratual ou dispositivo regulamentar administrativo nesse sentido, tal realidade não seria suficiente para a empresa demandada eximir-se de custear a técnica e a prótese, haja vista que tal procedimento configurou-se como indispensável à higidez física da paciente.

Em razão do quadro clínico da assegurada, considerar legal e admissível a intenção da parte ré de escusar-se do custeio do tratamento e do material específico requerido seria negar amparo e garantia ao bem jurídico maior tutelado pelo nosso ordenamento jurídico, qual seja, a vida.

O princípio constitucional do direito à vida e à saúde e do dever das seguradoras, em substituição ao Estado, oferecer sua escorreita prestação não devem ser considerados em planos inferiores aos dos casuísmos normativos ou contratuais, nem à burocracia das firmas contraentes, revelando-se direito líquido e certo da acionante, amparável na via ordinária, a reparação pelas expensas com a realização da cirurgia indicada, em situação de urgência ou emergência.

Além de tudo que restou exposto, não é outro entendimento dos tribunais brasileiros. Senão, confira-se:

> AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC, ART. 47. RECUSA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ACTEMRA (TOCILIZUMABE), SOB O ARGUMENTO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL – OFF LABEL. BULA DO MEDICAMENTO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO PARA A PATOLOGIA.
>
> 1. em substituição ao Des. Coimbra de Moura. DA PARTE. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. OBRIGAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MEDO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MEDICAMENTO LIBERADO APÓS TRÊS DIAS DA CONCESSÃO DA TUTELA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJPR – 9ª C.CÍVEL – XXXXX-79.2016.8.16.0030 – Foz do Iguaçu – Rel.: Juiz Guilherme Frederico Gernandes Denz – J. 22.03.2018)
>
> APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE ARTERITE DE CÉLULAS GIGANTES EXTRACRANIANA. PRESCRIÇÃO DO FÁRMACO ACTEMRA (TOCILIZUMABE). RECUSA DA OPERADORA. FÁRMACO APROVADO NA ANVISA. TRATAMENTO OFF-LABEL NÃO CONFIGURADO. USO INDICADO NA BULA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO REMÉDIO NO ROL DA ANS E SUAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA A DOENÇA DA AUTORA. IRRELEVÂNCIA. PATOLOGIA COBERTA PELO PLANO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO DIANTE DO INSUCESSO DE OUTRO TRATAMENTO. NEGATIVA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA EVIDENCIADO. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS PELA AUTORA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA DA REQUERIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJPR – 9ª C. CÍVEL XXXXX-78.2018.8.16.0021 – Cascave – Rel Juiz de direito substituto em segundo grau Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso – J. 11.02.2021)

Com efeito, nos contratos onde existem cláusulas que venham prejudicar a parte mais fraca da relação de consumo, em detrimento das máximas da boa-fé objetiva e da confiança, há que se as considerar abusivas, devendo ser reconhecidas judicialmente por meio de ação ou reconvenção, de exceção ou por ato *ex officio* do Juiz.

O artigo 51, incisos IV e IX do CDC, dispõe:

> Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)
>
> IV estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa fé ou a eqüidade; (...)
>
> IX deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor.

Sopesando, em conclusão todos os argumentos expendidos, tenho que se afeiçoa induvidoso que o pleito formulado pelo autor merece acolhimento.

A exclusão do dever de cobertura por cláusula contratual ou instrumentos de convênio firmados com terceiros, malgrado descrita em supostos estudos atuariais, constitui indisfarçável e frontal violação do regramento estampado na legislação protetiva do hipossuficiente porquanto soa implausível, eivada a não mais poder de abusividade e, *pour cète cause*, nula de pleno direito, o que fica aqui expressamente reconhecido e declarado, na forma do art. 52 inc. IV da Lei 8.078/1990, e art. 168 par. único do nCC (antigo, art. 146 par. único).

Quanto ao pedido indenizatório, exsurge nitidamente que ele merece prosperar nos termos os artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil.

O dano e a relação de causalidade estão presentes não só pela negativa de vigência do contrato, mas pelo sentido de perda em relação à reparação da saúde em momento delicado da vida do autor, objetivo primordial do procedimento médico irregularmente vetado.

Respeitante ao pedido alusivo aos danos morais, permite-se este Juízo deixar assentada breve conceituação pela qual "*danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico*" (SILVA, Wilson de Melo da - O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1995, n° 01).

Encampando esta linha de pensamento, confira-se a **Súmula 35 do TJPE**:

> "*A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral*".

Por certo, infligir ao paciente - profundamente debilitado pela moléstia que lhe acometeu - o ônus de vir a Juízo buscar a efetivação das suas prerrogativas, em detrimento da paulatina dor e sofrimento que se acha experimentando, significa vulnerar-lhe com absurda iniquidade a aprazia e o bem-estar, carecendo da pronta compensação financeira.

Por suposto, "*embora geralmente o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada*" (STJ - AgRg no REsp 1.328.978/RS - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - Julg. 13.11.2012 - DJe 20.11.2012)

O lesionamento, na espécie, não depende de prova de outros prejuízos ao patrimônio material, espiritual ou físico do postulante, porquanto se caracteriza *in re ipsa*.

Em conclusão, tenho ser indevida a recusa da parte ré em cobrir todas as despesas com o tratamento necessário ao paciente, nos termos solicitados pelo médico assistente, devendo suportar os custos com a cobertura devida em relação ao contrato celebrado entre as partes, por abusiva eventual cláusula de restrição, além de indenização por dano moral, esta arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerando a intensa extensão do dano suportado pelo autor e as condições pessoais das partes.

A jurisprudência mansa e pacífica dos Tribunais de Justiça assim vem entendendo em casos semelhantes:

> APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada procedente – Apelante que alega não estar sujeita às normas do CDC por tratar-se de plano de saúde do sistema de autogestão – Inadmissibilidade - O CDC é norma principiológica, de ordem pública e aplicável a qualquer relação de consumo – Plano de saúde pelo sistema de autogestão que se subordina à lei de regência – Inteligência do artigo 1º, § 2º da Lei nº 9.656/98 - Negativa de cobertura a tratamento de radioterapia IMRT sob o argumento de que a prescrição está em desacordo com as diretrizes do rol de procedimentos obrigatórios da ANS – Abusividade - Inteligência da Súmula nº 102 do E. TJSP – Procedimento de Radioterapia IMRT para região da cabeça e pescoço de acordo com as diretrizes do Rol da ANS, ao contrário do quanto alegado pela seguradora – Danos morais configurados e bem fixados – Recurso não provido.
>
> (TJ-SP - APL: 10048346420168260100 SP 1004834-64.2016.8.26.0100, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 20/03/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2017)

Por fim, cumpre assentar, por conveniente, que a liquidação dos danos morais em montante inferior àquele pretendido pela parte na peça de ingresso não importa sucumbência recíproca, nos exatos termos da Súmula 326, STJ.

Isto posto e por tudo mais que restou deliberado nos autos, tenho por imperativo **ACOLHER** a preliminar de ilegitimidade passiva do Hospital Real Português, excluindo-o da presente lide. Assim, por consequência, **condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios** sucumbenciais do Hospital Real Português, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), advertindo a suspensão quinquenal da cobrança, em virtude de ser o demandante beneficiário da gratuidade judicial, na forma do art. 98, §3º, CPC.

Em continuidade, julgo **PROCEDENTES** os pedidos que se acham contemplados na presente ação ordinária em face da parte ré remanescente para:

a) Condenar a parte ré Sul América na obrigação de fazer consistente em arcar integralmente com os custos do tratamento do autor implementado perante o nosocômio Hospital Português, conforme fatura de Id. 85667270 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3728613&ca=0f61623f53b88e64adc3a1b84d020b66ba976364d2506fbabdf18b22474b07415c7b5 para o que assino o prazo de cinco (5) dias úteis.

b) Imputar à demandada Sul América a obrigação de indenizar a parte postulante em aspecto compensatório pelos sofrimentos e danos extrapatrimoniais que valoro no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a repercussão e reprovabilidade do fato, bem assim a condição socioeconômica das partes litigantes (art. 944, nCC), quantia a ser monetariamente corrigida pela tabela ENCOGE desde este *decisum* (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação (art. 405, nCC).

Na oportunidade, extingo o presente feito por sentença com apreciação nuclear, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, imputando à ré Sul América os honorários advocatícios na ordem de 15% da condenação (obrigação de fazer + indenização), lastreado no art. 85, §2º, CPC/2015, além das custas processuais e taxa judiciária em aberto.

Independentemente de nova intimação, deverá a parte demandada/sucumbente **comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais** no prazo de quinze (15) dias úteis contados do trânsito em julgado, sob pena de que se oficie imediatamente ao Comitê Gestor de Arrecadação do TJPE (ou quem lhe faça a vezes) para adoção das providências de cobrança cabíveis, incluindo a multa de 20%, na forma dos arts. 22 e 27, §3º, da nova lei de custas (Lei Estadual nº 17.116/2020).

Intimem-se. Expeça-se.

Cumpra-se.

Recife-PE, 08 de agosto de 2022.

ROBINSON JOSÉ DE ALBUQUERQUE LIMA

Juiz de Direito Titular

jac

Assinado eletronicamente por: ROBINSON JOSE DE ALBUQUERQUE LIMA
09/08/2022 15:15:37
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 111757740

22080915153725600000109274092

IMPRIMIR GERAR PDF